

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、繁華街の通行人の面前で酒に酔い潰れて同意しない意思を表明することが困難な状態となっているAの衣類を剥ぎ取り全裸にした。この場合、甲に不同意わいせつ罪が成立するが、公然わいせつ罪は成立しない。
2. 甲は、人通りの多い路上で自己の性器を露出させたが、通行人は誰もそれに気付かなかった。この場合、甲に公然わいせつ罪は成立しない。
3. 甲は、わいせつな動画が収録されたDVDのレンタル業者乙に対し、同DVDを借りたい旨申し込み、乙から同DVDを借り受けた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。
4. 動画配信サイトを運営していた甲は、同サイト上でわいせつな動画を不特定多数の者に閲覧させて利益を得ようと考え、わいせつな動画の投稿者を広く勧誘し、その勧誘を受けた乙が同サイトにわいせつな動画を投稿して不特定多数の者が認識できる状態にした。この場合、上記サイトを運営していた甲は、わいせつな動画を自ら投稿しておらず、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の共同正犯が成立することはない。
5. 甲は、インターネットを介した不特定多数の者に対するわいせつな動画の販売業を始めたが、その購入を申し込んできた客は一人のみであった。甲は、その客のパーソナルコンピュータに対し、インターネットを介してわいせつな動画データを送信し、同コンピュータに同データを受信させて保存させた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。

№393	わいせつ罪等	正答率
R6-13	3、5（順不同）	92%

1 誤っている

大判明43.11.17は、不同意わいせつ行為を公然と行った場合につき、不同意わいせつ罪と公然わいせつ罪が成立し、両罪は観念的競合となるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、両罪の保護法益が異なることを挙げている。よって、本記述においては、繁華街の通行人の面前で酒に酔い潰れて同意しない意思を表明することが困難な状態のAの衣服を剥ぎ取って全裸にしているため、甲に不同意わいせつ罪だけでなく公然わいせつ罪も成立する。

2 誤っている

174条における「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいい（最決昭32.5.22）、現実には不特定多数の人が認識する必要はなく、その認識可能性があれば足りる。東京高判昭32.10.1は、本記述と同様の事案において、不特定多数の人が通行する可能性のある場所でわいせつな行為に及んだ場合には、たとえ現実にはその際に通行人が全くいなかったとしても、公然性に欠けることはないとしている。よって、本記述においては、誰も気付かなかったとしても、人通りの多い路上で自己の性器を露出させた甲に公然わいせつ罪が成立する。

3 正しい

わいせつ物頒布罪は、頒布の相手方の関与行為を必要とするが（必要的共犯）、相手方の関与行為については罰則がないので、頒布の相手方は、頒布罪の共犯としても処罰されない。よって、本記述においては、わいせつな動画が収録されたDVDの借りを申し込んだ甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯（61条1項・175条1項）は成立しない。

4 誤っている

最決令3.2.1（重判令3刑法2事件）は、管理者・運営者と各投稿者との間に、無修正わいせつ動画を投稿・配信することについて黙示の意思連絡があったと評価することができるとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪及び公然わいせつ罪の各共同正犯が成立するとしている。よって、本記述においては、動画配信サイトを運営してただけで、わいせつな動画を自ら投稿していない場合でも、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の共同正犯が成立し得る。

5 正しい

最決平26.11.25（百選Ⅱ101事件）は、刑法175条1項後段にいう「頒布」とは、「不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう」としている。そして、不特定かつ多数の者に頒布された場合のみでなく、不特定かつ少数の場合又は特定かつ多数の場合も、「頒布」に該当する。たまたま1名の顧客に交付・譲渡等したにすぎない場合であっても、それが不特定又は多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば、「頒布」に該当する（大判大6.5.19）。よって、本記述においては、一人の客に対してわいせつな動画データを送信し、その客のコンピュータに同データを受信させて保存させたにすぎない場合でも、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。

以上により、正しい記述は3と5であり、したがって、正解は肢3と肢5（順不同）となる。